

1502166-92.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... em poder do réu seriam destinadas ao tráfico.

Ou seja, diante da prova produzida em juízo, não se pode afirmar, com a certeza que exige o decreto condenatório, que o acusado estivesse praticando o tráfico de drogas nas circunstâncias descritas na denúncia.

A quantidade de drogas apreendidas em sua posse é pequena e, por si só, não denota a traficância, sendo perfeitamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502166-92.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502166-92.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2250909/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 14042627 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

10045/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2250909 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

3, 10045/20/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO LUIS HENRIQUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

RONALDO LUIS HENRIQUES está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea j, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, possuía e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico ilícito, nas quantidades de 1,210g de "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", acondicionados em 1 (um) invólucro plástico, e 4,440g de "cocaína" ("Metil Benzoil Ecgonina"), na forma de substância sólida amarelada e desprovida de invólucro individual. Notificado (fls. 145), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 157) e a denúncia foi

recebida (fls. 158).

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu. Ao final, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a sua absolvição por ausência de provas ou, em caso de condenação, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a não incidência da agravante referente à calamidade pública, a fixação do regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Embora a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu esteja comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/76), o caso é de absolvição, pelos fundamentos a seguir expostos.

A posse do réu sobre os entorpecentes apreendidos é incontroversa.

Sua confissão, neste particular, está corroborada pela prova oral produzida em juízo.

O caso, entretanto, é de reconhecimento da ocorrência de porte de droga para uso próprio.

Em seu interrogatório, o réu disse que é pessoa em situação de rua e que estava recebendo auxílio emergencial. Alegou que é usuário de drogas, que estava em posse dos entorpecentes apreendidos para uso próprio e que a quantia em dinheiro localizada era proveniente do auxílio emergencial que estava recebendo. Já quanto aos saquinhos plásticos disse que eram utilizados para fazer "gelinhos" para comercialização.

Negou a prática da traficância e alegou que estava no interior do quarto fazendo uso de drogas quando foi abordado. Acrescentou que é usuário de drogas há dez anos, que estava hospedado há dois dias no hotel e que os entorpecentes foram adquiridos no dia anterior à abordagem.

O policial militar Nilson relatou que estavam realizando diligências em virtude de uma ocorrência de roubo em que o indivíduo havia indicado o local onde estariam os produtos do crime, que seria o Hotel Galouro. No local, subindo a escada, depararam-se com o réu descendo e, ao avistar a equipe policial, tentou se evadir subindo no sentido contrário. Ele foi abordado e nas suas vestes foram localizadas porções de crack e de maconha. Quando indagado, ele informou o quarto onde estava hospedado. No cômodo mencionado, localizaram 1.080 reais em pequenas notas e vários saquinhos comumente usados para o embalo de entorpecentes.

Disse que o hotel é um dos principais pontos de tráfico da "baixada" e que os quartos costumam ser alugados por indivíduos para o fracionamento e distribuição dos entorpecentes. O depoente estava subindo a escada e o réu estava descendo, no sentido contrário. O que levantou a suspeita foi o fato de que ao ver a equipe policial o réu se assustou e tentou subir no sentido oposto.

Salientou que não se recorda se o acusado disse ser usuário de drogas e que o réu não informou a origem do dinheiro. Disse que os saquinhos apreendidos podem ser utilizados para fazer "gelinho" e que a única pessoa que estava no hotel era a recepcionista, que não informou nada sobre ter conhecimento de que o réu já era envolvido com o tráfico de drogas. Por fim, acrescentou que o réu foi abordado em data anterior na Praça Schmidt e nada de ilícito foi localizado com ele.

O policial militar Nilton informou que foi realizada uma abordagem de rotina no local e encontraram duas espécies de entorpecentes no bolso do réu. Quando indagado, ele informou que estava hospedado em um dos quartos do hotel, que é conhecido como ponto de tráfico e de usuários de drogas. Havia alguns papéis (plásticos) comumente utilizados no embalo da droga e no meio do colchão uma quantia em dinheiro.

Relatou que não havia uma quantidade muita grande de saquinhos plásticos, que não conhecia o réu e que não se lembra se o questionaram sobre ele ter passagens criminais. Recorda-se que ele disse ser usuário de droga, mas não se lembra da versão dele sobre o dinheiro apreendido. Por fim, disse que os papéis apreendidos são utilizados para embalar entorpecentes.

Pois bem.

A prova produzida sob o crivo do contraditório não demonstra, cabalmente, que as substâncias apreendidas em poder do réu seriam destinadas ao tráfico.

Ou seja, diante da prova produzida em juízo, não se pode afirmar, com a certeza que exige o decreto condenatório, que o acusado estivesse praticando o tráfico de drogas nas circunstâncias descritas na denúncia.

A quantidade de drogas apreendidas em sua posse é pequena e, por si só, não denota a traficância, sendo perfeitamente possível que um usuário contumaz faça uso dela em poucos dias.

Segundo o relato dos policiais militares, o acusado não foi visto praticando nenhum ato típico da traficância, pelo contrário, a abordagem foi ocasional, durante patrulhamento de rotina.

No mais, não foram apreendidos outros objetos indicativos da prática do tráfico de drogas, salvo pequenos saquinhos plásticos, cuja destinação não é exclusivamente acondicionar entorpecentes.

Em que pese a manifestação do Ministério Público em sede de alegações finais, ressalta-se que não se deve levar em consideração os antecedentes do réu, que responde especificamente pelo fato narrado na denúncia, nas específicas circunstâncias nela apontadas.

Inexistente prova segura do tráfico, portanto, o caso seria de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, já que, afinal, trazia consigo 1,210g de maconha e 4,440g de cocaína.

Ocorre que o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma penal incriminadora contida no art. 28 da Lei 11.343/06 é inarredável.

Inicialmente, deve-se ressaltar que não tem fundamento a falsa tese de que a lei teria descriminalizado o porte de droga para uso próprio, isto é, de que teria ocorrido a chamada abolitio criminis, ou mesmo de que a lei teria despenalizado tal conduta.

Ora, o art. 28 insere-se justamente no Capítulo III do Título III da lei 11.343/06, que trata precisamente "Dos Crimes e Das Penas", e dentre as sanções nele cominadas está a prestação de serviços à comunidade, que, por sua vez, é espécie de pena prevista pela Constituição (art. 5º, inciso XLVI, d).

Portanto, não há a menor base jurídica para se afirmar que a lei teria deixado de considerar crime tal conduta, muito menos que a teria despenalizado, sendo absolutamente insustentáveis tais teses.

O problema, evidentemente, não está no âmbito da legalidade.

Ao contrário, o problema do mencionado art. 28 é que a lei não pode definir como crime qualquer conduta, indiscriminadamente, que não constitua lesão a direito de outra pessoa além do próprio autor da ação (princípio da alteridade), sob pena de violar o direito à liberdade, inerente a todo ser humano e assegurado pela Constituição em seu art. 5º.

Só existe crime, em sentido material, se a conduta constitui lesão efetiva ou, ao menos, coloca em perigo real o direito de outrem.

Numa linguagem mais informal, poderíamos dizer que a lei não tem "carta branca" para definir indiscriminadamente condutas criminosas.

Não pode a lei, por exemplo, dizer que é crime "usar peça de vestuário da cor amarela nas quartas-feiras", porque isso simplesmente não lesa o direito de ninguém nem o coloca em perigo real.

Voltando ao caso do art. 28 em questão, não há como conceber que aquele que traz consigo pequena quantidade de droga para seu próprio consumo esteja lesando o direito de alguém. De que modo estaria a fazê-lo? A quem estaria lesando?

O sofisma de que tal conduta colocaria em risco a "saúde pública", obviamente, não guarda nenhuma relação com a realidade.

De que maneira aquele que porta pequena quantidade de droga, para seu próprio consumo, infligiria algum perigo para a "saúde pública"? Ainda na remota hipótese de que a pequena porção de droga, por algum motivo fortuito (perda, por exemplo), viesse a sair de suas mãos, de que maneira ela representaria algum perigo à saúde de quem quer que seja, a não ser de alguém que se apropriasse dela e a utilizasse livremente (caso em que, obviamente, não haveria lesão nenhuma a seu direito).

Poder-se-ia argumentar, ainda, que o portador da droga, ao usá-la, poderia vir a cometer algum crime e, por isso, representaria um perigo à sociedade. Este raciocínio é extremamente perigoso, porque a partir dele se deveria permitir, do mesmo modo, uma busca por infinitos outros fatores criminógenos e a consequente perseguição arbitrária, abusiva e tirânica de "potenciais criminosos" pelo estado. A este propósito, o filósofo, economista e historiador Murray Rothbard formula o seguinte princípio, que, sem dúvida alguma, deve balizar o âmbito de incidência do Direito Penal:

"(...) ninguém tem o direito de coagir qualquer pessoa que não esteja empenhada em um ato evidente de agressão contra direitos. Permitir um mínimo afrouxamento deste critério, para incluir coerção contra 'riscos' remotos, é sancionar agressões inadmissíveis contra os direitos dos outros. Além disso, qualquer afrouxamento deste critério é um passaporte para o despotismo ilimitado." (in A Ética da Liberdade, Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2ª ed., p. 316)

O que se percebe é que, sendo impossível identificar-se na conduta de portar droga para uso próprio qualquer ofensa, ou mesmo perigo de lesão a direito alheio, gerado diretamente por tal conduta, a sua criminalização acaba por sustentar-se exclusivamente na reprovação moral do ato em si.

Ocorre que, obviamente, não cabe à lei criminalizar atos reputados "imorais", desprovidos de qualquer potencial lesivo a direito de outrem (não existe o direito de exigir que outro indivíduo se comporte deste ou daquele modo), sob pena de se estabelecer inadmissível dirigismo autoritário de condutas individuais pelo estado. Portanto, é inevitável o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma penal incriminadora prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, por violar o direito fundamental à liberdade, sem que o justifique a defesa de nenhum outro direito que por tal conduta fosse violado.

Ante o exposto, desclassifico a conduta do réu RONALDO LUIS HENRIQUES para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, e, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade material da referida norma penal incriminadora, pelas razões acima expostas, absolvo-o, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em consequência, fica revogada a prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas, na forma legal, oficiando-se à autoridade policial para tanto.

Determino, após o trânsito em julgado, a restituição em favor do réu da quantia apreendida em seu poder, uma vez que não ficou provada sua relação com o tráfico de drogas.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 19 de abril de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA